



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 312/11
בקשה מס' 52/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

נציגות הבית המשותף רחוב יצחק שדה 34/36 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד דוד זיו
מרחוב מנחם בגין 7 רמת גן

המבקשת:
התובעת

- נ ג ד -

ליטל שמש ת.ז. 30117588
ע"י ב"כ עו"ד אלי כרוב
רח' בית עובד 13 (בית אריה)
ת.ד. 51550 תל-אביב 67211

המשיבה:
הנתבעת

ה ח ל ט ה

ההל"ך דנן עניינו בבית המשותף שברחוב יצחק שדה 34-36 תל אביב הבנוי על חלקה 44 בגוש 7067 (להלן: "הבית").

הנתבעת הינה בעלים של יחידה בבית (תת חלקה 65) (להלן: "הנכס").

בפני בקשה דחופה למתן צו עשה זמני המורה למשיבה להסיר את חיבורי הנכס למערכת סניקת ביוב, להסיר את חיבורי הנכס למערכת הביוב של הבית ולהורות על סילוק יד ופינוי השוכר שהפך את הנכס, המהווה חדרי משרדים, לחדרי מגורים.

לטענת המבקשת ביצוע פעולות חיבור הנכס למערכת הביוב ולמתקן הסניקה נעשה באופן פיראטי, לא מקצועי וללא קבלת הסכמת המבקשת. הפעולה מהווה שימוש אסור ברכוש המשותף, כיעור חזית הבית וגרימת נזק לרכוש המשותף. בדיון בפני התחרדרו טענות המבקשת לפיהן חלק ממערכות הסניקה כלל לא חוברו למערכת הביוב ולפיכך מתקני הסניקה עולים על גדותיהם או מפונים ידנית על ידי הדייר לתוך הרכוש המשותף. לפיכך, נתבקש הסעד המורה על פינוי השוכר מן הנכס.

המשיבה טוענת כי הבקשה צריכה היתה להיות מוגשת כנגד המחזיק ולא כנגד המשיבה, כי הבקשה הוגשה בשיהוי של כחודשיים מאז היוודע דבר חיבור המערכות וכי נעשית אכיפה סלקטיבית כנגד המשיבה (ולא כנגד אחרים אשר ביצעו פעולות דומות). עוד נטען כי מאז הנוחות נוטה לטובת המשיבה אשר צפויה להיות חשופה לתביעה מצד המחזיק. מאידך, אין כל נזקים בלתי הפיכים שייגרמו למבקשת, שתוכל לקבל את סעדיה במסגרת ההליך העיקרי. חיבור הנכס למערכת הביוב הינו שימוש סביר ברכוש המשותף שאינו מונע שימוש מקביל מאחרים. המבקשת נהגה בחוסר תום לב בהגשת הבקשה ובהמצאתה לידי המשיבה. כמו כן נטען כי קיימת זהות מוחלטת בין הצו הזמני לבין הסעד העיקרי וכי למפקח אין סמכות עניינית לדון בתובענה לפינוי השוכר. לפיכך נתבקשה דחיית הבקשה וחיוב המבקשת בהוצאות המשיבה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 312/11
בקשה מס' 52/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

בבואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים:

- א. **קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה:** בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (תקנה 362(א) לתקסד"א).
- ב. **שמירה על המצב הקיים:** מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה.
- ג. **מאזן הנוחות:** ביצוע הערכה של זכויות ושל תוצאות אפשריות לגבי שני הצדדים, של מתן או סירוב נתינתו של הצו הזמני. מבחן זה בודק את הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם לא יינתן הצו, לעומת הקשיים הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד הנתבע אם הצו יוענק לתובע.
- ד. **שיקולים שביושר** (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 502-503).

בין המבחנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שככל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אחר, פ"ד נו(1) 529); רע"א 10066/04 נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' פ.ס.ס. ספיר אנטרפרייז בע"מ, פ"ד נט(4) 700). עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא ינתן הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ [פורסם באתר נבו]).

בנסיבות דנן עסקינן, כאמור, בבקשה למתן סעד זמני מסוג צו עשה.

ההלכה קובעת כי צו כזה לא יינתן אלא במקרים יוצאי דופן: "קבלת סעד זמני מסוג צו-עשה זמני קשה יותר להשגה מאשר קבלת הסעד ההפוך (של צו מניעה זמני). בעוד שהסעד האחרון עומד בקריטריונים לעניין שמירת המצב הקיים, הרי שבמתן צו עשה זמני, יש, לכאורה, משום שינוי במצב הקיים" (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, (מהדורה תשיעית) בעמ' 527).

בבש"א (מחוזי-ת"א) 20818/03 מלכה שלמה נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ, [פורסם בנבו], נקבע: "על אף שבית המשפט מוסמך לתת צו עשה זמני (ר' הגדרת "סעד זמני) בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984) יימנע בית המשפט בדרך כלל מנתינתו. צו כזה יינתן רק במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר הנזק לתובע הוא בלתי הפיך ושום פיצוי כספי לא יוכל לתקנו...".

ברע"א 5843/05 איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה נ' שרון דן השקעות בע"מ [פורסם בנבו], נקבע: "הלכה היא, כי על בית המשפט לנקוט משנה זהירות טרם שיצווה על צו עשה זמני המשנה את המצב הקיים, עוד לפני שניתנה ההכרעה הסופית בתובענה. צו עשה זמני המשנה מצב קיים ראוי שיינתן במקרים חריגים, אך כאשר נוכח בית המשפט כי התערבותו הינה חיונית בכדי למנוע תוצאה קשה ביותר וכאשר הנזק שעלול להיגרם אינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם (ע"א 213/64 ברא"ז נ' נציב המים, פ"ד יח(3)



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 312/11
בקשה מס' 52/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

647, 653-654; וכן ראו רע"א 1868/98 סייג נ' המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי [פורסם בנבו]” (ההדגשה שלי, א.ס.).

לאחר שבחנתי את הבקשה ושמעתי את טיעוני הצדדים ולאור ההלכות האמורות לעיל, הגעתי למסקנה כי אין בנסיבות הבקשה דנן את אותו “מקרה יוצא מן הכלל” המצדיק מתן צו עשה זמני כמבוקש.

ראשית, אין מחלוקת כי מערכת הביוב של הבית הינה רכוש משותף. משכך, גם למשיבה הזכות, לכאורה, לעשות שימוש ברכוש משותף זה. השאלה הנדרשת לצורך ההליך הינה האם רשאית המשיבה לחבר את הנכס למערכת הביוב או שמה המדובר בהסגת גבול לרכוש המשותף.

לצורך הכרעה בשאלה מרכזית זו יש לקיים הליך של הוכחות במסגרתו תבחן השאלה האמורה, לרבות, השאלות המקצועיות הכרוכות בה. כך, בין היתר, תיבחן השאלה האם חיבור הנכס מונע חיבור של אחרים או גורם נזק למערכת. כך, אילו התאמות, אם בכלל, יש לבצע כדי לחבר את הנכס לצנרת הביוב. כך, אם ישנם אחרים אשר התחברו לצנרת הביוב ומה השפעת התחברותם על הצנרת. כל השאלות האלו, ועוד אחרות, מחייבות בירור עובדתי ומשפטי ואין מקום להכריע בהן כבר במעמד מתן החלטה בבקשה לסעד זמני בשלב מקדמי של ההליך.

שנית, המבקשת בחרה שלא לצרף את שוכר הנכס כמשיב בבקשה. במיוחד אמורים הדברים כאשר כבר מתשובות המשיבה לפניות המבקשת, עובר להגשת הבקשה (כפי שצורפו לכתב התביעה), עולה כי הסכסוך האמיתי הינו בין המבקשת לבין הדייר דווקא. התנהגותו של הדייר, היא זו אשר הביאה את המבקשת להגשת התובענה דנן. לפיכך, בעל דין נכון וראוי אינו צד לבקשה ועמדתו לא נשמעה בפני. במיוחד אמורים הדברים כאשר הסעד המרכזי המבוקש הוא פינויו של של אותו דייר מהנכס.

נוכחותו של השוכר גם נדרשת כדי שתהיה אפקטיביות כלשהי לצו המבוקש. אין זה ראוי לחייב את המשיבה בסעד זמני שגם המבקשת עצמה מבינה כי לא יהיה בידה לבצעו (ר' בהקשר זה התייחסות ב"כ המבקשת לשוכר בעמוד 3 שורות 10-13).

שלישית, במסגרת הערכת מאזן הנוחות יש להתחשב בעובדה כי חלפו למעלה מחודשיים מאז חובר הנכס, לכאורה, למערכות סניקה וביוב ועד להגשת התובענה דנן. לו היה הכרח מיידי במתן סעד, סביר כי המבקשת היתה פונה באופן דחוף. העובדה כי חלפו מספר חודשים מאז קרות האירועים (אף אם נוצלו לצורך הידברות עם נציג המשיבה כנטען) יש בה ללמד על כי אין דחיפות משמעותית במתן הסעד כפי שנטען.

גם לא התרשמתי מן הבקשה כי אי מתן הצו עשוי לגרום, בדרך כלשהי, לנזק שאינו ניתן לפיצוי כספי הולם, ככל שתתקבל התובענה בסופו של יום. אומנם, נטען כי בעלי הדירות סובלים מפעולות השוכר בנכס, לרבות, ריחות הביוב. אולם, קבלת הבקשה מביאה לשינוי המצב העובדתי הקיים (פינויו של השוכר) ועשויה לגרום למשיבה דווקא נזק משמעותי.

חמישית, קיימת זהות בין הסעד הזמני המבוקש בהליך שבפנינו לסעד הקבוע המבוקש בהליך העיקרי. עקב כך, קבלת הבקשה עלולה, במידה רבה, לייתר את המשך הדיון בהליך העיקרי. אומנם, אין בעובדה זו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 312/11
בקשה מס' 52/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

כשלעצמה כדי לשלול מתן סעד זמני כשזה נדרש, אך שיקול זה מצטרף לשיקולים האחרים כאמור לעיל המטים את כף מאזן הנוחות ושיקולי היושר לכיוון דחיית הבקשה (רע"א 4196/93 שפ"ע בר נ' שפ"ע מסעדות ייצור ושיווק פד"י מז(5) 165).

שישית, לאחר שבחנתי את כתב התביעה בתיק זה הגעתי למסקנה כי הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר. לכך גם מודע, למעשה, ב"כ המבקשת (עמוד 1 שורות 24-25). ובמה דברים אמורים.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"). בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 הנ"ל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמוע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסוימת, עשה זאת במפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 71 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 71 להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

במסגרת התובענה מבקשת התובעת שני סעדים מרכזיים, כפי שהגדיר זאת בא כוחה בדיון בפני – "אנחנו מבקשים סעדים שיורו למשיב להתנתק מצינור הביוב, אנחנו מבקשים לסלק את השוכר מהחדרים שלו" (עמוד 1 שורות 24-22). בנוגע לחיבור הנכס למערכת ביוב, הרי שלטענת המבקשת חלק מצנרת הביוב של הנכס מחוברת למערכת סניקה (שאינה רכוש משותף) וחלק למערכת הביוב המרכזית.

התביעה והבקשה, מבוססים על טענות מכח דיני התכנון והבניה ואפשרויות השימוש בנכס. עילת התביעה מתבססת גם על דיני הנזיקין, בעיקר, עילת המטרד. כך, בודאי, בכל הקשור לטענות בדבר פינוי השוכר, שאינן טענות בהן מוסמך המפקח לדון על פי סעיף 72 לחוק כאמור.

אולם, הדברים נכונים גם ביחס לטענות בנוגע לחיבור מערכת הביוב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 312/11
בקשה מס' 52/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

עבודות חיבור הנכס לביוב (העבודות בפנים הנכס וחיבורו למערכת הסניקה, להבדיל מצינור הביוב המשותף) אין בהן, כשלעצמן, הפרה של הוראת סעיף 2(א) לתקנון המצוי. אלא, כפי שעולה מן הבקשה ומכתב התביעה, השימוש אותו עושה השוכר בנכס (לרבות בפינוי מערכת הסניקה לתוך הרכוש המשותף), הוא זה אשר גורם לנזקים הנטענים.

בכל הקשור לטענה בדבר חיבור הנכס שלא כדין למערכת הביוב המשותפת מוסמך המפקח לדון. אולם, המדובר, למעשה, בטענה בדבר הסגת גבול לרכוש המשותף, לגביה קיימת סמכות מקבילה לבית משפט השלום (ס' 72(ב) לחוק).

נוסף לכך, מכתב התביעה עולה כי, גם בהקשר זה, עילת התביעה המרכזית של המבקשת היא סוגיית השימוש בפועל בנכס על ידי השוכר. ב"כ המבקשת מאשר בדיון בפני כי הטענות אינן מופנות כלפי בעלי דירות ומחזיקים אחרים היות ואלו "גרים שם אבל הם לא מתחברים בלי רשות ולא מטנפים. הם מדברים עם הוועד שחי שם ומבצעים את מה שהוועד מבקשת אותם" (עמוד 3 שורות 9-8). כלומר, השימוש בפועל בנכס הוא עיקרה של התובענה.

גישת הפסיקה היא שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות. כך גם נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט גרסטל, בע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן ואח' (לא פורסם): "...ספק רב אם ניתן להעביר חלק מהתביעה לבית משפט אחר, בעוד שחלק אחר נותר לדיון בפני המפקחת".

במיוחד אמורים הדברים כאשר פיצול התובענה באופן כזה שבפני תידון שאלת חיבור הנכס למערכת הביוב של הבית בלבד, לא יתן פתרון לסוגיות השימוש בנכס (לרבות במערכת הסניקה), שהן הן הסוגיות העיקריות, העומדות על הפרק.

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה למתן צו עשה זמני.

בכל הקשור להמשך הדיון בתובענה העיקרית, הרי שבפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 צ.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב – יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירנו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 312/11
בקשה מס' 52/11

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך לדון בתובענה.

בנסיבות דנן לא מצאתי לנכון ליתן צו להוצאות.

אומנם, המשיבה נדרשה להשיב לבקשה וזו נדחתה בסופו של דיון. אולם, בתגובתה המשיבה מתחמקת, למעשה, מאחריותה כבעלת נכס כלפי בעלי היחידות האחרים בבית ומבקשת להטיל על המבקשת את "הטיפול" בשוכר הנכס מטעמה. זאת ועוד. למבקשת ולמשיבה אינטרסים משותפים ופסיקת הוצאות בבקשה עשויה להעיב על יכולת הצדדים להגיע להסדר בהליך כולו, לטובת כל בעלי הדירות.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לצדדים באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי בתאריך כ"ו סיון תשע"א, 28 יוני 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב